

第2節 正当行為

刑法
No.77

H30-5

(配点: 4)

月 日

月 日

違法性に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

- ア. 殺人被告事件の弁護人が、同被告事件の真犯人は被告人の兄であると考え、第一審の有罪判決後に行った記者会見で「同被告事件の真犯人は被告人の兄である。」旨発表した場合、弁護活動の一環として行ったものであるから、正当な業務行為として違法性が阻却され、名誉毀損罪は成立し得ない。
- イ. 宗教家が、異常な言動を示すようになっていた娘を連れてきた信者の求めに応じ、その娘の不調の原因を取り去る目的で、宗教上の行為として、同人の身体を手で押さえ付け、流れ落ちる滝の水を同人の顔面に打ち当てた結果、同人を窒息死させた場合、宗教活動の一環として行ったものであるから、正当な業務行為として違法性が阻却され、傷害致死罪は成立し得ない。
- ウ. 現行犯人を逮捕しようとする私人が、犯人から抵抗を受け、逮捕のために社会通念上必要かつ相当な範囲で実力を行使し同人に傷害を負わせた場合、法令による行為として違法性が阻却され、傷害罪は成立し得ない。
- エ. 借地人が、自己の借地内にある自己所有の店舗を増築する必要に迫られ、その借地内に突き出ている隣の家屋の屋根をその所有者の承諾なく切除した場合、自救行為として違法性が阻却され、建造物損壊罪は成立し得ない。
- オ. 新聞記者が、取材の目的で国家公務員に秘密漏示を唆した場合、取材の自由は憲法上保障される表現の自由由来し、十分尊重されるべきであるから、正当な業務行為として違法性が阻却され、国家公務員法違反の罪（秘密漏示教唆罪）は成立し得ない。

No.77	違法性						正答率
H30-5	正解	ア 2	イ 2	ウ 1	エ 2	オ 2	81%

ア 誤っている

最決昭51.3.23は、本記述と同様の事案において、「その行為は、訴訟外の救援活動に属するものであり、弁護目的との関連性も著しく間接的であり、正当な弁護活動の範囲を超える」としている。その理由として、判例は、「名誉毀損罪などの構成要件にあたる行為をした場合であつても、それが自己が弁護人となつた刑事被告人の利益を擁護するためにした正当な弁護活動であると認められるときは、刑法35条の適用を受け、罰せられない……。……刑法35条の適用を受けるためには、その行為が弁護活動のために行われたものであるだけでは足りず、行為の具体的状況その他諸般の事情を考慮して、それが法秩序全体の見地から許容されるべきものと認められなければならないのであり、かつ、右の判断をするにあつては、それが法令上の根拠をもつ職務活動であるかどうか、弁護目的の達成との間にどのような関連性をもつか、弁護を受ける刑事被告人自身がこれを行つた場合に刑法上の違法性阻却を認めるべきかどうかという諸点を考慮に入れるのが相当である。……被告人らは、Fら三名が真犯人であることを広く社会に報道して、世論を喚起し、Aら兩名を無罪とするための証拠の収集につき協力を求め、かつ、最高裁判所の職権発動による原判決破棄ないしは再審請求の途をひらくため本件行為に出たものであつて、Aらの無罪を得るために当該被告事件の訴訟手続内において行つたものではないから、訴訟活動の一環としてその正当性を基礎付け余地もない」ということを挙げている。

イ 誤っている

最大判昭38.5.15は、本記述と類似の事案において、「被告人の本件行為は、……一種の宗教行為としてなされたものであつたとしても、それが……他人の生命、身体等に危害を及ぼす違法な有形力の行使に当るものであり、これにより被害者を死に致したものである以上、被告人の右行為が著しく反社会的なものであることは否定し得ないところであつて、憲法20条1項の信教の自由の保障の限界を逸脱したものというほかはなく、これを刑法205条に該当するものとして処罰したことは、何ら憲法の右条項に反するものではない」としている。その理由として、判例は、「被告人の本件行為は、被害者Aの精神異常平癒を祈願するため、……加持祈祷の行としてなされたものであるが、被告人の右加持祈祷行為の動機、手段、方法およびそれによつて右被害者の生命を奪うに至つた暴行の程度等は、医療上一般に承認された精神異常者に対する治療行為とは到底認め得ない」ということを挙げている。

ウ 正しい

最判昭50.4.3は、本記述と同様の事案において、「現行犯逮捕をしようとする場合において、現行犯人から抵抗を受けたときは、逮捕をしようとする者は、警察官であると私人であるとを問わず、その際の状況からみて社会通念上逮捕のために必要かつ相当であると認められる限度内の実力を行使することが許され、たとえその実力の行使が刑法法令に触れることがあるとしても、刑法35条により罰せられない」としている。

エ 誤っている

最判昭30.11.11（百選I19事件）は、本記述と同様の事案について、自救行為による違法性阻却を認めなかった原判決を正当としている。その理由として、判例が正当とした原判決（札幌高函館支判昭28.11.10）は、「無許可の不法建築であつても、その侵害を排除するため法の救済によらずして自ら実力を用いることは法秩序を破壊し社会の平和を乱し、その弊害たるや甚だしく現在の国家形態においては到底認容せらるべき権利保護の方法ではない。正当防衛又は緊急避難の要件も具備す

る場合は格別、漫りに明文のない自救行為の如きは許さるべきものではない」ということを挙げている。

オ 誤っている

最決昭53.5.31（百選Ⅰ18事件）は、「報道機関が取材の目的で公務員に対し秘密を漏示するようにそそのかしたからといって、そのことだけで、直ちに当該行為の違法性が推定されるものと解するのは相当ではなく、報道機関が公務員に対し根気強く執拗に説得ないし要請を続けることは、それが真に報道の目的からでたものであり、その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されるものである限りは、実質的に違法性を欠き正当な業務行為というべきである。しかしながら、報道機関といえども、取材に関し他人の権利・自由を不当に侵害することのできる特権を有するものでないことはいうまでもなく、取材の手段・方法が贈賄、脅迫、強要等の一般の刑罰法令に触れる行為を伴う場合は勿論、その手段・方法が一般の刑罰法令に触れないものであつても、取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しく蹂躪する等法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認することのできない態様のものである場合にも、正当な取材活動の範囲を逸脱し違法性を帯びる」としている。よって、新聞記者が取材の目的で国家公務員に秘密漏示を唆した場合、正当な業務行為として違法性が阻却されず、国家公務員法違反の罪（秘密漏示教唆罪）が成立する場合がある。